

平成14年6月1日

ストック・オプション課税についての意見書

三木義一(立命館大学法学部教授)
(法学博士・一橋大学)

一 本意見書の課題

本件の中心的争点は、外国親会社から日本子会社の役員にストック・オプションが付与され、当該役員がオプションの権利を行使した際に生じる経済的利益（＝以下、「権利行使益」という）が、所得税法に規定されている「給与所得」に該当するのか、それとも「一時所得」に該当するのか、である。本意見書は、この争点に限定して、長年税法を研究してきたもの者の立場から意見を申し述べるものである。

二 被告の主張

この問題について、被告課税庁は本件権利行使益を「給与所得」に該当すると主張しているが、その根拠を整理すると次のようになる。

まず、給与所得の要件は①役務提供の対価であり、かつ、②その役務提供が雇用関係に類する関係において提供されたことの2点が必要であるとする（準備書面（5）5頁等）。

そして、①の要件については、「対価」を広く役務提供に由来すれば足りるというという前提の下で（被告準備書面（5）26頁）、次のように述べている。

「本件ストック・オプション付与契約は、原告の日本インテルに対する役務提供から、原告が権利攻勢期を与えるに足りる役務提供を行うと評価されたことを原因とし、一定期間勤務したときに、現実にもその権利行使益を与えることが相当と認められたことから、一定期間の役務提供を条件として、その後の役務提供における精勤にも期待する趣旨で、退職により権利行使期間を制限して、ストック・オプションを付与したもので、権利行使益を与えるに値する原告の精勤に対する報酬として権利行使益を移転する趣旨のものと認められる。すなわち、本件ストック・オプション付与契約は、原告の日本インテル社に対する役務提供に由来して原告にストック・オプションを付与する趣旨にほかならず…所得税法上、役務提供の対価に当たるものと評価される。」（被告準備書面（5）29頁）

次に②雇用関係に類する関係の存在については、ややわかりにくい点があるが、学説や昭和56年4月24日最高裁第2小法廷判決（民集35巻3号672頁）等を引用した上で「給与所得における雇用契約に類する関係とは、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受けた役務の提供であれば足り、厳密な意味での雇用契約等である必要はない」とし、本件のような「親会社から子会社従業員に対する親会社株式のストック・オプションについてみると、…その付与

契約は、子会社との雇用契約の従たる契約であって、与えられるストック・オプションは子会社での一定期間の勤務等の条件が付されていることから、従業員等がこれによる経済的利益を得るためには、付与会社である親会社との関係で、子会社に一定期間勤務するとともに行使時において子会社に勤務していることが必要となる。上記条件は、正に、昭和56年祭高裁判決にいう『給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受けた役務の提供』の要件に該当する」(被告準備書面(1)17頁)と主張している。

被告は、給与所得を上記のように広くとらえるとともに、他方で一時所得については「一時的かつ偶発的かつ恩恵的」な所得と定義し、「この要件を一つでも満たさない所得は、一時所得には該当しないことになる」とも断言している(被告準備書面(6)4頁)。なお、このような理解は、一時所得という所得類型の基本的性格を全く誤解したものであり、この点は後に詳述したい。

三 企業グループと課税単位・租税法律主義

上記のように、被告が給与所得の範囲を広く解そうとする事情は、被告の次の主張から読みとれる。「特に、近時は商法の会社分割法制の整備等からもうかがわれるように、我が国内においても分社化や持株会社の設立といった企業の組織再編が活発化し、企業組織が多様化するに伴い、企業グループ全体による人材活用が進んでいることも指摘されている……。このように多様化した企業組織の下では、雇用契約や委任契約といった伝統的な契約類型までまかない切れなような雇用形態が現れてきており、また、報酬制度も、本件において問題とされているストック・オプション制度をはじめ多様化している。このような現状に背を向け、雇用契約や委任契約という契約類型や契約上の反対給付という性質のみに着目し、直接の雇用会社からの給付でないことのみを理由に給与所得該当性を否定するときには、そうした所得は雑所得といわざるを得ず、到底、担税力に応じた公平な課税を実現することはできないことは明らかである」(被告準備書面(5)21頁)。

確かに、被告の主張するような状況が生じていることは事実である。しかし、だからといって、納税者に経済的負担等を課す税法において、従来の解釈・適用基準を安易に変更してよいわけではない。何よりも、税法は租税法律主義の原則が支配し、納税者の予測可能性を担保しなければならない、そうだからこと、様々な事情の変更に対応すべく毎年税法改正が行われているのである。被告主張のような事情は何よりもまず立法において考慮すべきことである。とりわけ、本件の争点である親会社から

子会社役員へのストック・オプション付与は、確かに一種の一体感のようなものが支給の基礎にあるが、親会社と子会社の役員には被告も認めるように雇用契約関係はないのであり、しかも親会社に事実上勤務するような実態もないのである。被告はこの弱点を、究極的には、企業グループ内の雇用を一企業内の雇用関係に擬して考えることによって乗り越えたいとしていることになる（前記被告準備書面（５）２１頁）。

しかし、この主張は明文の根拠もなく、税法の基礎にある課税単位を実質的に変更する重大な問題を含んでいる。周知のように、わが国の課税制度では組織変更税制や現在審議中の連結納税制度導入までは、課税単位を個人単位・法人単位とし、グループ間の特殊性は特例規定がない限りは（例えば、所得税法第５６条、法人税法６２条の２）、別人格間の行為として課税されてきたのである。

例えば、大阪地裁昭和５７年５月４日判決（税務訴訟資料１２３号２８１頁）では、原告が、原告会社と子会社間の経営指導料等の授受について経済的実質的に一体的な関係者なので当該授受を寄付金とすべきでないと主張したのに対し、被告である課税庁自身が「会社間の取引について当該各会社が、全体として統一した経営意思により経営されていたり利害関係を共にしたりあるいは親子会社等の特別な関係がある場合であっても、法に特別の規定がない限り特別な取り扱いは許されない。原告とその子会社とは別個の独立した法人格を有し、それぞれの目的に従って独立の法主体として、法律行為、取引あるいは経済活動を行っているものであるから、これらの法人を一括して同一の経済主体とみることはできない。原告が子会社との間に原告主張の如き実質関係があったとしても原告が別個独立の法主体の形態をとった以上、その形態に応じた法的効果を受けるのは当然である。」と断言してきたのである。

また、判決もこれを支持し「原告は、子会社が経済的、実質的観点から原告の分散工場であり、原告と同一経済主体であることを理由に、原告と子会社間の経営指導料等の授受について寄付金を問題にし得ない旨主張するが、原告及び子会社が別個独立の法人格を有し、それが各別に法律行為、経済取引をしている以上、その間にその形態に応じた法的効果を生じ、それが課税の対象として捉えられることがあることはいうまでもないから、単に経済的観点から同一の権利主体である者の間に寄付がありえないという原告の右主張は採用できない」と判示している（控訴審である大阪高裁昭和５８年９月３０日判決税務訴訟資料１３３号８０８頁も原審を支持）。

あるいは、被告はこのような主張は会社間の取引についてであって、本件のように会社と役員との関係には適用できない、との反論をされるかもしれないので、あらかじめ指摘しておく、このようにグループ企業であってもそれぞれ別人格を有している以上、グループ内の一企業と役員との関係をグループ内の他の企業との関係においても同視あるいは類似の関係とみることを判例実務は否定してきているのである。例えば、東京高裁平成12年1月26日判決（訟務月報46巻12号4365頁）では、グループ企業の役員であった被相続人の債務控除可否の認定に際して、原告が、主たる債務者であるグループ内一法人の状況だけではなく、グループ企業全体の状況に基づき弁済不能であるか否かを判断すべきであると主張したのに対し、被告・課税庁は「なお、各法人は、それぞれ独立の法人格を有するものであり、その債務は各法人固有の債務であるから、親子会社の関係にあることをもって、当該法人が、他の法人の債務について法的責任を負うことはない。したがって、主たる債務者らが弁済不能の状態に陥っていたか否かについては、子会社との連結決算を基にして判断されるべきであるとの控訴人の主張は理由がない」とこれを否定し、判決も「確かに、支配従属関係にある2つ以上の企業集団を単一の組織体とみなし、親会社又はグループ会社全体の財政状態及び経営成績ないし支払能力を把握するためには、連結決算を基にするのも1つの有益な手法であると認められる。しかし、親会社及び子会社は、それぞれ別個独立の法人であり、しかも、親会社を生き残らせるために採算のとれない特定の子会社のみを整理することは必ずしも珍しいことではなく、その場合には、法律上、親会社の子会社に対する債権の回収、親会社の子会社に対する債務の弁済、子会社の債権者に対する保証債務の弁済等により両者の関係が処理されるものであり、右のような関係を把握するためには、親会社と子会社との債権債務関係が反映された親会社独自の決算によることが必要であり、それで十分である」と判示してきているのである。

このようにグループ関係にある企業であっても、法に特別な規定がない限りは、別個独立した者でありその一企業と行った契約関係を他のグループ内企業との関係に同視できるわけではないのである。本件においてもこの前提で租税法律関係を理解しなければならない。

本件ストック・オプションは、親会社から子会社の役員に支給され、かつ、当該役員が親会社に対して何らの勤務関係を義務づけられていない以上、法的には少なくとも、親会社と子会社役員との間に雇用契約又はこれ類する関係があるとはいえない。仮にこのようなグループ間の関係を広義の雇用関係もしくは委任関係に類す

るものとして課税するのであれば、少なくとも税法上明文のみなし規定が必要であり、しかも、ストック・オプション問題がわが国で議論されるようになってから何度も税制改正の機会があったのであり、このような租税法律主義の要請に基づく手続を履行せずに、解釈で課税単位という重大な課税要件の質的変更を含む変更はとうてい許させるものではない。

四 一時所得の基本概念と被告の主張

また、被告課税庁は自らの主張を有利にするために意図的に一時所得の範囲を限定し、「一時的かつ偶発的かつ恩恵的」（準備書面（6）3頁等）に限定されている。しかし、これは明文規定にない条件を勝手に付加したものであり、この点でまず大きな誤りを犯している。現行法によれば一時所得は、①「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得」で、②「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」でなければならず、③「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない」という条件は付いているが、「恩恵的」という要件までは規定していないからである。また、現行実務では競馬による払戻金や満期保険金なども一時所得に含めて課税しているが（所得税基本通達34-1（2）（4）等参照）、これらの一時的利得が恩恵的な利得とはいえないことは明らかであろう。これらは、むしろ計画的とさえいえるし、保険満期金については資金提供に対する対価性も全くないわけではないのである。しかし、これらは「確実性」のない一時的な所得であるため一時所得の対象に含まれてきたのである。従って、一時所得は恩恵的どころか計画的なものであっても、その実現が不確実で（その意味での偶発性）、一時的に発生する利得を広く含んでいるのである。このことは、一時所得という所得類型の成立及びその後の改正過程からも説明できるのである。

周知のように、戦前の所得税制の下では一時的な所得は課税対象外であったが、昭和22年の改正で第9条第1項第8号に、一時所得の所得類型が設けられ「前各号以外の所得で営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とされた。ここで、注目すべきは、一時所得は他の所得類型には該当しない利得のうち、継続的営利行為以外の一時的な利得を広く課税対象とするものであり、当初から明確な範囲を定めて設けられたものではない、ということである。つまり、一時所得という所得類型は、当時の所得類型のうち「事業等所得」（同9号）と並んで他の所得に該当しないものを広く対象にする補充的な所得類型で、そのうち、一時的なも

のを課税対象にするものであったのである。従って、雑多な一時的利得から、他の所得類型に移した方がよいものが徐々にその後の改正で他の所得類型に移されていき、例えば、翌年の改正では動産の処分益が一時所得から譲渡所得に組み替えられ、昭和25年の改正では「事業等所得」が「不動産所得」「事業所得」「雑所得」に細分化されたのに伴い、「雑所得」とともに補充的な機能を果たす所得類型となり、さらに27年の改正では「役務の対価たる性質」を有する一時所得が雑所得に移されたことにより、作家以外の人を受け取る原稿料等のように労務の対価性が明確なものは一時的なものであっても雑所得に変更されたのである。いずれにせよ、一時所得は被告主張とは全く異なり、中心的概念として「一時性」「偶発性」が重視されているものの、それ以外の要素も実に雑多に含まれているといわざるを得ないのである。

例えば、本件で問題となっている「労務その他の役務の対価」性の問題についても、確かに27年改正で、労務等との対応関係が明確で、当該労務に対して通常確実に支払われるものは、雑所得に移されたが、労務の対価性の要素が一時所得から全く排除されたわけでもないのである。例えば、現行実務でも労働基準法114条に基づき給付される付加金を一時所得に含めているが（所得税基本通達34-1（3）参照）、これは当該受給者の使用者に対する労務の提供がなければあり得ない給付であるが、支給されることが確実ではないことからきているのである。また、人格のない社団等の解散による清算分配金や払戻金（所得税基本通達34-1（6）参照）も当該構成員の労務が無関係とまではいえないが、その対応関係は通常の収益の分配等に比して間接的で、取得の可能性も不確実なので一時所得に分類されているのである。

要するに、一時所得は被告が主張するように「一時的かつ偶発的かつ恩恵的」な所得に限定されているわけではないし、また、厳密な意味で一切の労務対価性が排除されているわけでもないのである。これは、前述のように、一時所得がもともと他の所得を補充する所得類型として設けられたことに起因しており、厳密な意味でその範囲を限定された所得類型ではなく、現行法においても利子所得から譲渡所得に該当しない所得を広く対象にし、そのうち雑所得に分類できない一時的なものをこの類型で課税することにしているのである。本件の所得分類を判断するに際してはこの点が重要な視点となる。

五 一時所得・給与所得分類のメルクマール

一時所得は雑所得と並んで補充的な所得類型であり、一時性（偶発性）を重視した所得類型であったこと、次第に労務の対価性が明確なものが除かれるようになってきたこと、また、給与所得が基本的に雇用関係又はそれに類する関係に基づき、当該労務の対価として支給されるものであること考慮して、一時所得と給与所得等を分類すると、①「雇用関係等の有無及び不明」、②「労務の対価性の有・不明」、③「給付の確実性の有無」の3要素の組み合わせにより、次のように所得分類されることになろう。

【第1類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくもので、かつ、労務の対価性も明確で、給付が確実なもの」

この場合の所得は、典型的な給与所得になるいうまでもない。

【第2類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくもので、かつ、労務との対価性が必ずしも明確ではないものの、定期的に支給され、給付が確実なもの」

このような所得としては、いわゆる通勤手当が考えられるが、これは労務自体の直接の対価とは言い難いが、労務を提供するために必要なもので、労務の対価に準じて評価されるべきものとして給与所得に該当することになろう（最高裁第2小法廷昭和37年8月10日判決・訟務月報9巻1号83頁等参照）ある

【第3類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくもので、かつ、労務の対価性が認められるものの、給付が不確実なもの」

このような所得としては、使用者が使用人に対して支給する報償金のうち支給を受ける者の考案等が通常の職務の範囲内の行為である場合の報償金等であるが、これは給与所得に該当すると解して良いであろう（所得税法基本通達23～35共1（3）を参照）。

【第4類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくものであるが、労務の対価性が不明確で、しかも給付が不確実なもの」

このような所得としては、使用者が使用人に対して支給する報償金のうち支給を受

ける者の考案等が通常の職務の範囲外の行為である場合の報償金等であるが、これは一時所得になると解されるし、現行実務もそのように扱っている（所得税法基本通達23～35共－1（3）を参照）。

【第5類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくものか不明であるが、労務の対価性も明確で、給付が確実なもの」

このような所得は、労務の対価性がある以上、当該労務の独立性の有無により、事業所得（独立性有）、給与所得（独立性無）に分かれ、前者はその規模等の総合判断によって雑所得になる場合もある。

【第6類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくものか不明であり、労務の対価性も不明であるが、給付自体は定期的で、確実なもの」

このような所得は、雇用関係も労務の対価性も不明である以上、補充的な所得分類である雑所得か一時所得になるが、定期的に支給され、確実に支給されるのであれば雑所得に分類される。

【第7類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくものか不明であるが、労務の対価性はある、ただ給付自体は不確実なもの」

このような所得は、労務の対価性がある以上、当該労務の独立性の有無により、事業もしくは雑所得（独立性有）、給与所得（独立性無）に分かれ、前者の場合には受給が不確実である以上通常は事業としての客観性を欠いているので雑所得に分類されることになろう。

【第8類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくものか不明であり、かつ、労務の対価性も不明確で、給付も不確実なもの」

このような所得は補充的な所得分類である雑所得か一時所得になるが、給付が不確実である以上、偶発的な所得であり一時所得となろう。現行実務で一時所得に含めている、人格のない社団等の解散により受けるいわゆる清算分配金又は脱退

により受ける持分の払戻金等はこの所得類型に属するものと思われる(所得税法基本通達34-1(6)参照)。

【第9類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくものではないが、労務の対価性も明確で、給付が確実なもの」

この場合は労務の対価性があり、当該労務が雇用関係等ではないので、原則として事業所得であり、事業規模に至らない場合は雑所得に分類されることになる。

【第10類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくものではなく、かつ、労務の対価性も不明確であるが、給付自体は定期的で、確実なもの」

このような所得は補充的な所得分類である雑所得か一時所得になるが、定期的、確実に支給される以上一時所得ではなく、雑所得となる。

【第11類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくものではないが、労務の対価性はある、ただ給付が不確実なもの」

この場合は労務の対価性があり、当該労務が雇用関係等ではないので、事業所得か雑所得になるが、給付が確実でない以上事業とはいえず、雑所得になる。実務が雑所得として扱っている、使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等から受ける贈与等がこれに該当しよう(所得税法基本通達35-1(12)参照)。

【第12類型】

「雇用関係もしくはそれに類する関係に基づくものではなく、かつ、労務の対価性もなく、かつ、給付が不確実なもの」

法人から業務に関係せず一時的に受ける給付などが該当するが、この所得が典型的な一時所得になる。

現行所得税法が基礎においている以上のような分類方法に本件権利行使益を当てはめてみると、本件行使益が権利を付与された者に確実に与えられているものではなく、株価の上昇という偶発的な要素によって発生するものであることは明らかで

ある。すると、該当可能性があるのは3, 4, 7, 8, 11, 12類型となる。次に、支払者に直接労務を提供していないこと、支給者と雇用関係等の法的関係がないことからすると、被告の主張を最大限考慮しても雇用関係の有無が不明確で、かつ労務の対価性も不明確といわざるを得ないので、3, 4, 7の所得類型には該当しない。そうすると、残された可能性は、8, 12であり、どちらに分類しても現行所得税法上一時所得であることは変わりないと思われる。

七 本意見書のまとめ

以上のように、本件ストック・オプションの権利行使益は、雇用関係もしくはそれに類似する契約関係に基づき支給されるものではなく、支払者に何ら直接的労務提供をしていない以上、労務の対価性を基本的に欠いている。仮に、被告主張のようにグループ内の広義の労務提供関係が認められたとしても、まず第1に、当該労務に基づき取得できる利益の発生が不確実であること、第2に、当該労務と利益発生との関係がきわめて間接的・偶発的であることからして、原告主張のように給与所得や雑所得に含まれるのではなく、一時所得に含まれると解するのが、所得税法に則した自然な解釈である。

なお、このことと企業再編成に際して、企業グループ及びその従業員間の関係を税法上どのように規律していくことが公平かという問題とは別であり、企業再編にふさわしい課税関係を構築していくことは立法の重要課題であることはいうまでもない。

意見書作成者の略歴及び主要著書

一 略歴

昭和 25 年 生まれ

昭和 48 年 3 月 中央大学法学部卒業

昭和 50 年 3 月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和 50 年 11 月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和 55 年 4 月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和 55 年 10 月 同 助教授

平成 4 年 4 月 東京大学社会科学研究所助教授併任

(5 年 3 月まで)

平成 5 年 3 月 法学博士 (一橋大学)

平成 5 年 4 月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 6 年 4 月 立命館大学法学部教授 現在に至る

(なお、平成 10 年 4 月～10 月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官)

二 主要著書

2001 年 有斐閣『よくわかる税法入門』

清文社『世界の税金裁判』(編・著)

清文社『税理士春香の事件簿』

2000 年 一粒社『相続・贈与と税』

1998 年 ぎょうせい『逆転裁決精選 50』(編・著)

1995 年 信山社『受益者負担制度の法的研究』(日本不動産学会著作
賞・東京市政調査会藤田賞受賞)

勁草書房『争点相続税法』(編・著)

1992 年 勁草書房『現代税法と人権』

日本住宅総合センター『ドイツの住宅税制』(編・著)

1990 年 青木書店『消費税の研究』(共著)

1988 年 ぎょうせい『租税手続法活用事典』

1986 年 有斐閣『うまい酒と酒税法』(編・共著)

1982 年 有斐閣『地方自治法の論点』(共著)

その他、学術論文、等多数。

上記に相違ありません。 平成 14 年 6 月 1 日

立命館大学法学部教授 三 木 義 一